

第6節 横領の罪

刑法
No310

H19-13

(配点：3)

月	日
月	日

学生AないしEは、次の【事例】における乙に対する横領罪の成否について、後記【発言】のとりの意見を述べた。乙に対する横領罪の成立を肯定する意見を述べた学生を選んだ場合、その組合せとして正しいものは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

乙は、甲から、公務員丙に対し甲所有の宝石を賄賂として贈ることを依頼されてその宝石の交付を受けたが、その後、この宝石を売却してその代金を自己の用途に費消しようと考え、この宝石を売却した。

【発言】

学生A. 民法第708条にいう「給付」とは、終局的利益を与えるもの、すなわち所有権付与を意味し、甲が贈賄の目的に基づいて乙に宝石を寄託することは不法原因給付には当たらない。

学生B. 民法と刑法とでは目的が異なる。この事例では、委託者甲の側に保護に値する利益があるかどうかという視点から考えるべきであり、窃盗犯人の占有する盗品の窃取を処罰すべきであることとの均衡も考慮すべきである。

学生C. 甲から乙への宝石の交付は民法第708条の不法原因給付に当たるから、不法原因給付物である宝石の所有権は、甲が乙に対し宝石の返還を請求できないことの反射的效果として乙に帰属するに至った。

学生D. 横領罪の目的物は単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているにすぎず、必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求することができることを要件としていない。

学生E. 私の考えと反対の考え方を採ると、民法上宝石の返還義務のない者に宝石の返還を強制することとなり、全体としての法秩序の統一性を破ることになる。

1. A、D
2. B、C、E
3. A、B、C
4. A、B、D
5. C、D、E

(参照条文) 民法

第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

本件【事例】は、最判昭23.6.5（百選Ⅱ63事件）に主題を求めたものである。

A 肯定

学生Aは、「民法第708条にいう『給付』とは、終局的利益を与えるもの……を意味し、……寄託することは不法原因給付には当たらない。」と発言している。したがって、学生Aは、不法原因給付と不法原因寄託を分けて考える立場に立っていることがわかる。このように両者を分けて考える立場においては、学説上、不法原因給付については、民事判例が、給付者が給付物の返還を請求し得ないことの反射の効果として、その所有権は受給者に帰属するとしている以上、不法原因給付物は受給者にとって「他人の物」ではなく横領罪（252条1項）が成立しないと解されている。これに対し、不法原因寄託物については、学生Aのいうように不法原因給付にあらず、その結果、不法原因寄託物は受給者にとって「他人の物」にあたり横領罪が成立し得ると解されている。そして、学生Aは、本件宝石の交付につき、「甲が贈賄の目的に基づいて乙に宝石を寄託することは不法原因給付には当たらない。」と発言しており、不法原因「寄託」であると考えていることがわかる。したがって、学生Aは乙に対する横領罪の成立を肯定する意見を述べている。

B 肯定

学生Bは、「民法と刑法とでは目的が異なる。」と発言した上で、本件事例につき、「委託者甲の側に保護に値する利益があるかどうかという視点から考えるべき」と発言している。これは、民法と刑法ではその目的が異なる以上、民法で保護しないものについて、刑法上絶対に保護しないわけではないことを前提に、たとえ民法上不法原因給付にあたり委託者甲が返還請求権を行使し得ない場合（すなわち、保護されない場合）でも、委託者甲の側に刑法上保護に値する利益があれば、横領罪の成立を肯定すべき、という趣旨の意見であるといえる。したがって、少なくとも学生Bは、本件事例につき民法上不法原因給付にあたるから直ちに横領罪の成立を否定すべき、とする意見ではないことがわかる。

次に、学生Bは、「窃盗犯人の占有する盗品の窃取を処罰すべきであることとの均衡も考慮すべき」と発言している。これは、窃盗犯人の占有する盗品の窃取を処罰する以上、いくら贈賄目的のものであっても、預かった金員を着服する行為には、横領罪としての当罰性を認め得る、すなわち委託者甲の側に刑法上保護に値する利益がある、という趣旨の意見であるといえる。したがって、学生Bは乙に対する横領罪の成立を肯定する意見を述べている。

C 否定

学生Cは、「甲から乙への宝石の交付は民法第708条の不法原因給付に当たる」と発言した上で、その「宝石の所有権は……乙に帰属するに至った。」と発言している。このように宝石の所有権が乙に帰属したと考える以上、乙にとってその宝石は「他人の物」とはいえず、横領罪の構成要件を満たさないことになる。したがって、学生Cは乙に対する横領罪の成立を否定する意見を述べている。

D 肯定

学生Dは、252条1項は、「必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求することができることを要件としていない。」と発言している。このように、民法上返還請求ができない場合でも刑法上横領罪は成立し得ると考える以上、本件事例のように民法上不法原因給付にあたり民法第708条により甲が乙に返還を請求することができない場合でも、横領罪は成立し得ることになる。したがって、学生Dは乙に対する横領罪の成立を肯定する意見を述べている。

E 否定

学生Eは、「私の考えと反対の考え方を採ると、」「民法上宝石の返還義務のない者に宝石の返還を強制することとな」と発言している。「民法上宝石の返還義務のない者」とは、すなわち民法上不法原因給付を受領した受給者を指す。そして、その者に「宝石の返還を強制することとな」というのは、すなわち宝石の返還をしなかった場合に横領罪の成立を肯定するということを指す。そうすると、学生Eの発言の趣旨は、Eと反対の考え方を採ると、本件事例において受給者乙に対する横領罪の成立を肯定することとなり、それが「全体としての法秩序の統一性を破ることに」なり不当である、とするものであるといえる。したがって、学生Eは乙に対する横領罪の成立を否定する意見を述べている。